

1501212-11.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento pacífico da jurisprudência – tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal – de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501212-11.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501212-11.2022.8.26.0228

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Réu:

CAIO CESAR SOUZA NEVES ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

CAIO CESAR SOUZA NEVES ROCHA (RG. 39740655/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, letra “j”, do Código Penal, porque, no dia 14 de janeiro de 2022, durante calamidade pública e pandemia decretada pelo Governo do Estado de São Paulo em virtude do Covid-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), por volta das 17h00min, na Rua Epaminondas Melo do Amaral, altura do nº 1.140, Casa Verde, nesta cidade e Comarca de São Paulo, transportava e trazia consigo, para a entrega e consumo de terceiros, 19 (dezenove) papелotes de cocaína, totalizando 12,5 gramas; 20 (vinte) papелotes de crack, totalizando 2,1 gramas; e 01 (uma) embalagem da substância tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como “maconha”, totalizando 1,3 gramas, cf. auto de exibição e apreensão 8 e laudo de constatação de fls. 10/13.

Segundo o apurado, na data e local descritos acima, o denunciado transportava e trazia consigo os entorpecentes acima listados, acondicionados no interior de uma bolsa, enquanto na condução da motocicleta CG 160, cor vermelha e placas GCJ-4320/SP.

Enquanto trafegava pela Rua Epaminondas Melo do Amaral, na altura do numeral 1.140, o denunciado avistou uma viatura policial, em patrulhamento de rotina. Com isso, o denunciado demonstrou exacerbado nervosismo, motivo pelo qual foi abordado pelos policiais militares.

Em revista pessoal, na bolsa que o denunciado trazia consigo, os milicianos apreenderam 19 (dezenove) embalagens contendo a substância cocaína, 20 (vinte)

embalagens contendo a crack e 1 (uma) embalagem contendo "maconha". Autuado em flagrante delito e conduzido ao Distrito Policial, em interrogatório formal perante a digna Autoridade Policial, CAIO alegou que adquiriu o entorpecente apreendido junto a si para consumo pessoal (fls.14). Em 25 de janeiro de 2022, foi determinada a notificação do acusado (fls. 89/90) e, nos termos do artigo 26 do Provimento CSM n.º 2564/20 e na necessidade de prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi reservada na modalidade virtual. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. Em seguida, a denúncia foi recebida, sendo iniciada a instrução criminal. Durante a fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Quanto à pena, manifestou-se pelo não cabimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante da reincidência. Por sua vez, a defesa postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o porte de substância entorpecente, a fixação de pena mínima, regime mais brando, direito de recorrer em liberdade, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do delito de tráfico de drogas, em período de calamidade pública.

Ao final da instrução criminal, apesar dos argumentos da nobre defesa, é de rigor a PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal. Senão vejamos:

A materialidade do delito resultou provada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 08), laudo de constatação (fls. 10/13) e laudo pericial químico-toxicológico (fls. 150/152), que constatou que o material apreendido continha substância entorpecente, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

No entanto, no que diz respeito a autoria, é de rigor a desclassificação para o delito de porte de substância entorpecente. Senão vejamos

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: a quantidade e o tipo de droga, bem como as circunstâncias do flagrante, não autorizam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas estavam na posse do réu, não sendo o caso de absolvição. No entanto, a finalidade comercial do entorpecente não restou cabalmente demonstrado, sendo de rigor a desclassificação para o porte de substância.

Assim, durante o interrogatório policial, o réu CAIO disse que andava de motocicleta, quando foi abordado por policiais militares que encontraram drogas em sua posse. Brigou com sua namorada e adquiriu as drogas para seu consumo pessoal, sem declinar onde as conseguiu (fls. 14).

Em Juízo, o réu CAIO tornou a negar a traficância e contou que à época dos fatos trabalhava como pintor, mas seu pai acabou amputando a perda pela diabetes e passou a ajuda-lo na venda de churrasco. Ganhava em cerca de trinta reais por dia. Morava em casa própria. Na época fazia uso habitual de drogas. Estava fora de controle. Misturava crack com maconha. Tinha alucinações. Não vendia drogas. No dia dos fatos estava embriagado e fazendo uso de drogas e fizeram um comentário de que sua esposa o estava traindo. Ficou louco. Pegou cerca de 290 reais que tinha em casa e comprou as drogas, ou seja, 20 pedras e 19 cocaínas e uma maconha. Pretendia usar as drogas para acabar com sua vida. Na realidade os policiais salvaram sua vida.

Apesar dos argumentos do Parquet, a negativa do réu não pode ser de todo afastada em face da prova colhida nos autos, pois somente a quantidade das drogas, isoladamente, não tem o condão de provar a finalidade do entorpecente.

Neste sentido:

"STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento pacífico da jurisprudência – tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal – de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, em recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso, embora o réu haja sido preso em flagrante em local conhecido por intenso tráfico de drogas, ele, em nenhum momento, foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros (aliás, nem vendendo, nem comprando drogas); ou seja, ele não foi encontrado, na rua, em situação de traficância. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da prática de tráfico de drogas pelo recorrente; não houve, ainda, uma investigação anterior que apontasse o réu como traficante. Apenas houve a apreensão de pequena quantidade de drogas em seu poder (12,89 gramas de cocaína). De outro lado, a própria defesa não negou a propriedade da droga, afirmando, no entanto, que era para consumo próprio. Ainda, mas não menos importante, vale o registro que o réu, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes. 3. A conclusão das instâncias de origem (e do próprio Ministério Público Federal) de que o réu seria traficante pelo simples local em que foi preso em flagrante – em bairro conhecido por intenso tráfico de drogas – foi firmada com base apenas em indício de que ele seria traficante de drogas, e não em elementos robustos e conclusivos de que estaria havendo a prática do crime de tráfico. Vale dizer, o que se tem dos elementos coligidos aos autos é apenas a intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agravado. Somente aliado a outros meios de prova é que o local da abordagem do réu poderia basear o convencimento do juiz acerca da traficância. Não há, pois, como subsistir a conclusão de que houve a prática do crime de tráfico de drogas. 4. Nada impede que um portador de 12 gramas de cocaína, a depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). [...] (STJ; AgRg no AREsp 1636869/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – grifo nosso

Assim, no caso dos autos, os agentes da lei declararam que o réu foi abordado pois estava pilotando a moto em velocidade. Ele acabou parando a moto e estava visivelmente exaltado. Contaram que o réu, antes mesmo de ser abordado declarou que portava drogas. Indagado sobre as drogas, aduziu que pretendia usa-las para tirar a própria vida, devido a um desentendimento com sua esposa.

Assim, a testemunha MATEUS, policial militar, em Juízo, reconheceu o réu e narrou que ao final de uma abordagem na avenida, passou a moto com o réu, acelerando fortemente. Deram ordem de parada, ele não atendeu, foram atrás e logo depois ele parou. Na abordagem, ele levantou as mãos e disse que estava portando drogas. Ele estava com uma bolsa com cerca de 40 a 50 porções de drogas. Havia drogas variadas, cocaína, crack e maconha. Ele alegou que havia brigado com a mulher e teria comprado para uso pessoal. Disse que pretendia consumir todas as drogas e se matar. Ele não disse onde comprou. Não conhecia o réu até a data dos fatos. Não encontraram anotações ou dinheiro. O local exato da abordagem não é ponto de venda de drogas, mas existem ponto nas proximidades. O réu estava muito exaltado.

Da mesma forma, a testemunha TIAGO, policial militar, em Juízo, relatou que estavam abordando um moto na via. Liberaram a moto e em seguida apareceu a moto do réu, fazendo barulho. Deram ordem de parada e ele fugiu. Foram atrás e 50 metros adiante ele parou e colocou as mãos ao alto dizendo que estava com drogas. ele disse que havia brigado com a esposa e que havia adquirido as drogas para consumir e se matar. Não conhecia o réu até a data dos fatos. O local da abordagem não é ponto de

venda de drogas.

Em suma, os policiais confirmaram, de maneira uníssona, que o réu foi detido na posse das drogas, bem como que o réu negou a finalidade da traficância, não estava em atitude suspeita, em ponto de venda, na posse de valores ou anotações.

Da leitura dos depoimentos, bem como diante da ausência de outras provas aptas ou indícios a indicar a finalidade espúria das drogas, resta claro que não é possível afastar a negativa do réu, no que diz respeito à finalidade comercial, bem como acatar a tese de porte para o uso das drogas apreendidas.

Noto, por oportuno, que o réu não foi flagrado na comercialização, não portava quantia em dinheiro, não estava em ponto de venda, não tinha anotações ou outros petrechos e, ainda, não confessou a traficância, mesmo que informalmente, a finalidade comercial.

De outra feita, a quantidade apreendida, ou seja, cerca de 15 gramas, não afasta a possibilidade de reconhecimento do delito de porte, em especial diante dos demais elementos e circunstâncias da prisão.

O réu declarou ser usuário de entorpecentes, bem como afirmou que pretendia usar as drogas para tentar contra a própria vida, em todos os momentos em que foi ouvido, não havendo nos autos outras circunstâncias que indicassem estar ele fazendo o tráfico.

A quantidade, nestas circunstâncias, isoladamente, não é apta a embasar um condenação, pois não havendo provas contundentes quanto à finalidade de comercialização, é de rigor afastar o decreto condenatório pelo crime mais grave. Diante do exposto, é de rigor a desclassificação do delito descrito na peça acusatória para o delito previsto no artigo 28 da Lei Especial, com a condenação, apenas e tão somente, pelo porte de substância entorpecente, que ficou cabalmente comprovado, tanto pela confissão na fase policial e em Juízo, como pelo restante da prova oral produzida.

No mais, inadmissível se falar em inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei 11.342/2006. Primeiro, restou superada a tese de que a pequena quantidade da droga desnatura o delito, nem exclui a tipicidade do fato (STF, RT 814:509 e 812:490; RJTJSP, 105:447, 107:445), em especial diante da quantidade apreendida nestes autos. De outro lado, a tese de que a conduta é inconstitucional porque violadora do princípio da intimidade e da vida privada, prejudicando apenas o usuário, não merece acolhida, pois o dispositivo previsto no aludido artigo visa proteger a saúde pública, prevalecendo o interesse coletivo quando confrontado com o individual (nesse sentido: TJSP, RT 819:581).

Desta forma, inexistente qualquer inconstitucionalidade no artigo 28 da Lei Antidrogas, consoante vem, reiteradamente, decidindo a jurisprudência: TJSP, ACrim 72.037, RT 650:273; ACrim 151.129, 5ª Câmara, rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150:307, e RT, 702:334; TJSP, RT, 666:292).

Passo a dosagem da pena.

As circunstâncias judiciais autorizam a majoração da pena e a fixação de prestação de serviço a comunidade pelo prazo de 03 (três) meses. Ciente da condição de seu genitor, auferindo poucos rendimentos, o acusado gasta o dinheiro que recebe com drogas, retirando do sustento de sua família. Outrossim, levando em conta às consequências nefastas do delito, que consome a saúde física e mental não apenas do réu, mas também de seus familiares, a pena de prestação de serviço a comunidade mostra-se mais adequada. Diante da reincidência, majoro a pena supra para 4 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade. Não há atenuantes a serem consideradas. Não existem causas diminuição ou aumento de pena. Transformo, pois, a pena supra em definitiva.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, desclassifico o delito de tráfico, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, conforme descrito na denúncia, para o delito de porte de entorpecentes, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06, e, em consequência, CONDENO o acusado CAIO CESAR SOUZA NEVES ROCHA (RG. 39740655/SP), à pena de 04 (QUATRO) MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE, na forma do artigo 28, parágrafo 5º da Lei nº 11.343/06. Assim, o réu deverá prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas com atribuição de tarefas gratuitas, na forma que for conveniente à Instituição a ser

indicada pelo Juízo da Execução, devendo a prestação ocorrer em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais, levando em conta sua aptidão, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

Em caso de descumprimento da pena supra, aplica-se o disposto no artigo 28, parágrafo 6º, da Lei 11.343/06.

Em face da pena aplicada terá o direito de recorrer em liberdade, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA clausulado.

Transitada esta em julgado, o réu terá o seu nome lançado no "Rol dos Culpados".

Por fim, autorizo sejam incineradas as drogas apreendidas, providenciando a serventia as comunicações de praxe.

Custas não são devidas.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de março de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA